

1500341-47.2021.8.26.0185

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Mateus Lucatto De Campos

Comarca: Estrela D'Oeste

Foro: Foro de Estrela D'Oeste

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas. Narra ainda que, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 18:10 horas, na Rua Guanabara, n. 60 - Centro, na cidade de Estrela d'Oeste/SP, os denunciados, agindo em concurso, com unidade de propósitos e identidade de desígnios, adquiriram e transportaram, para fins de tráfico, 04 (quatro) tabletes e 02 (duas) grandes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Estrela D'Oeste

Foro de Estrela D'Oeste

1ª Vara

Rua Minas Gerais, s/n, Estrela D'oeste-SP - cep 15650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500341-47.2021.8.26.0185 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500341-47.2021.8.26.0185

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2259743/2021 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS PLANTÃO, 20423695 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS PLANTÃO, 1055/21/709 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS PLANTÃO, 2259743 - DISE- DEL.SEC.FERNANDÓPOLIS, 1055/21/709 - DISE- DEL.SEC.FERNANDÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIGOR VINICIUS RODRIGUES MARIA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mateus Lucatto De Campos

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu "denúncia" em face de HIGOR VINICIUS RODRIGUES MARIA e EDUARDA PEDROSO RODRIGUES, já qualificados nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da lei n. 11.343/06 c.c. o art. 29 do Código Penal; e art. 35, "caput", da lei n. 11.343/06, em concurso material. Narra a denúncia que, desde data anterior não precisada até o dia 22 de setembro de 2021, os denunciados associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas. Narra ainda que, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 18:10 horas, na Rua

Guanabara, n. 60 - Centro, na cidade de Estrela d'Oeste/SP, os denunciados, agindo em concurso, com unidade de propósitos e identidade de desígnios, adquiriram e transportaram, para fins de tráfico, 04 (quatro) tabletes e 02 (duas) grandes porções de Cannabis Sativa L ("maconha"), com massa total líquida de 3,875 quilogramas, sem autorização legal ou regulamentar. Autuados em flagrante, foi concedida a liberdade provisória à acusada Eduarda e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva do acusado Higor (fls. 72ss). A denúncia veio acompanhada de elementos colhidos na fase investigativa e foi recebida em 26 de outubro de 2021 (fls. 145). Citados (fls. 179; e 181), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 167ss; e 182ss). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas. Os réus foram interrogados. Finda a instrução, as partes apresentaram suas razões finais. O Ministério Público pediu a procedência integral da ação penal, sustentando que as provas produzidas comprovam a autoria e a materialidade delitiva de ambos os delitos imputados aos acusados. Por sua vez, a Defesa da corré Eduarda Pedroso Rodrigues pediu sua absolvição, argumentando pela insuficiência de provas e do in dubio pro reo; que a acusada não carregava qualquer droga e não tinha conhecimento da existência da droga; subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito no art. 28, da lei 11.343/06, eis que a acusada é apenas usuária. Por fim, a defesa do acusado Higor Vinicius Rodrigues Maria apresentou preliminares de cerceamento de defesa; de nulidade do interrogatório disfarçado de oitiva informal; e da ilegalidade da invasão domiciliar e prisão preventiva; no mérito, pediu a absolvição do acusado por insuficiência probatória; ou, subsidiariamente, o reconhecimento da forma privilegiada do delito de tráfico de drogas - art. 33, §4º, da lei n. 11.343/06; argumenta pela inexistência de vínculo associativo entre o casal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, respeitado o entendimento dos doutos Defensores, entendemos que todas as objeções preliminares formuladas pela defesa do corréu Higor devem ser afastadas. Com efeito, não há de se falar em cerceamento de defesa. Como já deliberado anteriormente, o art. 191 do Código de Processo Penal é expresso ao mencionar que "Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente.", sendo que tal dispositivo visa manter a lisura dos depoimentos, evitando a influência de um corréu sobre o outro ou mesmo o ajuste da mesma narrativa. Conforme doutrina:

"O objetivo maior, entretanto, é evitar que, no mesmo instante em que um corréu está sendo ouvido, o outro absorva a narrativa, podendo ser influenciado emocional ou psicologicamente pelas declarações, alterando as suas, por sua conta e risco, podendo representar, para a sua defesa técnica, a pior opção. Por isso, não se tem por meta fazer com que o interrogatório seja uma peça imparcial e genuinamente idônea, porque não faz parte da sua natureza, mas sim que não existam influências momentâneas, prejudiciais à defesa daquele que altera a sua versão, somente porque ouviu o interrogatório precedente do corréu." (Guilherme de Souza Nucci - Código de Processo Penal Comentado; 2014)

Aliás, entendemos que os precedentes invocados pela d. defesa, data venia, não são aplicáveis ao caso concreto, pois, em verdade, não houve autorização para que o corréu que ainda não depôs acompanhasse o interrogatório do outro. Vale dizer, o réu Higor foi interrogado primeiramente, não tendo sido autorizado que a corré Eduarda acompanhasse seu interrogatório, sendo retirada da "sala virtual". Ademais, a Defesa da corré Eduarda sequer se insurgiu contra essa circunstância (a indicar até mesmo ausência de "legitimidade" para impugnar tal fato). Aliás, não foi estritamente negado que o corréu Higor acompanhasse o interrogatório de Eduarda (afinal, já tinha sido interrogado), havendo de se anotar que em audiência houve a concordância de todos os presentes com a "liberação" de Higor para retornar para sua rotina no interior do estabelecimento prisional, ponto no qual houve inclusive concordância de sua defesa, afinal ausente prejuízo (foi expressamente questionado

por este Magistrado se poderia "liberar" Higor, após seu interrogatório, não havendo objeção). Em outro vértice, mesmo diante da menor probabilidade de influência em razão da prévia ocorrência de interrogatório (Higor) antes da seguida oitiva de corréu (Eduarda), vige ainda a mesma disposição do CPP, porquanto ainda há a possibilidade de que um corréu constanja o outro (em caso de insistência por permanência, ele seria retirado invariavelmente, retornando apenas em caso de justo pleito nesse sentido). Outrossim e ainda na análise dos precedentes invocados, observa-se que as defesas de Higor e Eduarda puderam, por óbvio, fazer reperguntas aos outros corréus, não havendo qualquer limitação ao exercício da defesa durante a produção da prova ou violação ao contraditório. Enfim, a autodefesa foi realizada (interrogatórios), e nenhuma limitação à defesa técnica foi empreendida, inexistindo qualquer laivo de ilicitude nos atos realizados. Dessa forma, entendemos que não foram apresentadas razões suficientes para afastar a disposição legal que veda expressamente o pleito formulado pela defesa.

Em desfecho ao ponto, a defesa não provou qualquer prejuízo, de modo que há de se aplicar o disposto no art. 563 do CPP, que impõe a impossibilidade de se declarar nulo qualquer ato que não resultar em efetivo prejuízo para a acusação ou para a defesa. Prejuízo à licitude das provas, data venia, ocorreria se permitido verdadeiro interrogatório "conjunto" dos réus, mormente se considerado que a responsabilidade penal é pessoal (art. 5º, inciso XLV, CF), havendo de se inquirir cada um por si ao final dos atos.

Em seguimento, não há o que se falar em nulidade de eventual "entrevista" disfarçada de interrogatório, pois, em verdade, tal fato sequer ocorreu. Como se depreende da instrução probatória, os policiais ouvidos afirmaram que nenhum dos corréus quisera "colaborar" e dar informalmente sua versão sobre os fatos. Vale dizer, ambos os réus permaneceram silentes aos questionamentos que lhes foram endereçados pelos policiais civis, sendo que o policial Augusto Kanamaru mencionou expressamente que não "forçou" eles a darem sua versão, ante ao direito constitucional de permanecer em silêncio. Assim, entendemos que a alegação defensiva é desprovida de substrato fático que lhe forneça "utilidade", pois se observa que o Ministério Público sequer tenta utilizar qualquer "informação informal" dada pelos acusados em desfavor deles mesmos. Ademais, não é proibido que policiais conversem com cidadãos investigados e abordados durante uma diligência, mas sim que lhes neguem silêncio diante de ocasião de documentação de suas oitivas em razão de eventual ilícito, por qualquer meio. Portanto, aqui também não há nulidade a ser reconhecida.

Por fim, e de igual forma, também não há ilegalidade na busca domiciliar realizada. Com efeito, novamente entendemos que a tese defensiva carece de "utilidade" em sentido processual, pois a busca domiciliar não resultou na colheita de qualquer elemento probatório desfavorável aos acusados (policiais não apreenderam nada no interior da residência). Vale dizer, se houvesse ilegalidade na busca domiciliar, a consequência seria a declaração de nulidade dos elementos probatórios colhidos na diligência. Entretanto, como já dito, nada foi encontrado no domicílio, sendo diminuta a utilidade decorrente do eventual reconhecimento da tese. Não obstante, em tarefa de argumentação, há de se consignar que não vislumbramos mácula nos procedimentos policiais. Nesse sentido, os policiais mencionaram que ingressaram no imóvel após o acusado Higor ter se desvencilhado de grande quantidade de "maconha" (isto na frente da residência), sendo que, de início, tinham o intento de capturar o acusado, que empreendera fuga; e, em seguida, realizaram buscas no imóvel (mas que nada localizaram). Assim, diante da grande quantidade de "maconha" desvencilhada pelo acusado, havia elementos indiciários suficientes para concluir para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que o estado flagrancial constitui exceção constitucionalmente expressa à inviolabilidade do domicílio - art. 5º, XI, da Constituição Federal. Vale dizer, o ilícito não foi reconhecido com a entrada em dito domicílio, mas antes, em via pública, sendo o local privado usado no contexto dos autos como mero ambiente de fuga. Assim, não há ilegalidade nas

atividades investigativas.

Passo ao mérito.

A pretensão penal deduzida em juízo é parcialmente PROCEDENTE. Com efeito, finda a instrução probatória, entendemos que a autoria e materialidade vieram demonstradas a contento apenas com relação ao delito previsto no art. 33, "caput", da lei n. 11.343/06. Neste ponto, a materialidade delitiva está configurada. É o que se extrai dos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante (fls. 01ss); boletim de ocorrência (fls. 03ss); auto de exibição e apreensão (fls. 51); laudo de constatação (fls. 53ss); laudo de exame químico-toxicológico (fls. 127ss); e, notadamente, pelas provas orais colhidas na fase investigativa e em contraditório judicial. De igual modo, a autoria de HIGOR e EDUARDA está configurada. Vejamos.

O policial civil GILSON APARECIDO DURAN, em juízo, disse que uns 15 (quinze) dias antes dos fatos participou de uma operação policial desencadeada pela polícia civil de Estrela d'Oeste/SP, no cumprimento de mandados de busca e apreensão, sendo que um dos alvos principais eram os acusados Higor e Eduarda; que na ocasião foi encontrada pouca quantidade de droga, não tendo sido feito o flagrante; que durante a operação, alguns vizinhos se aproximaram e pediram ajuda; que é morador de Estrela d'Oeste/SP e já trabalhou na cidade, por isso tem certo contato com as pessoas dali; que as pessoas pediam ajuda, pois havia um movimento muito grande de usuários que vinham até a casa dos acusados; que na data dos fatos um pessoa ligou, dizendo que naquela data havia uma movimentação e que ele achava que iria ocorrer alguma coisa naquele dia; que foi com uma equipe até a cidade de Estrela d'Oeste/SP e montaram uma campanha próximo à casa da genitora do acusado Higor; que por volta de 18:00h viram quando um veículo parou defronte a casa, sendo que o casal Higor e Eduarda desceram do veículo; que Higor trazia consigo uma sacola, motivo pelo qual resolveram abordar; que quando se aproximaram e Higor viu que era a polícia, ele soltou a sacola e saiu correndo em direção aos fundos; que na sacola que ele deixou estava a droga dentro; que Higor foi detido por outra equipe que estava nos fundos da casa; que todos foram apresentados no Plantão Policial; que a operação policial que participou ocorreu cerca de 15 (quinze) dias antes dos fatos, mas que, por ser morador de Estrela d'Oeste/SP, já tinha informações do envolvimento do casal há cerca de 05 ou 06 meses antes; que as informações indicavam participação do casal; que na época dos fatos eles moravam juntos, mas era a casa da genitora de Higor que era apontado como "ponto" de vendas; que não se recorda a cor da sacola que Higor carregava; que antes dos fatos a DISE de Fernandópolis/SP não tinha feito investigações contra os acusados, pois a operação policial que participou foi feita pela Delegacia de Estrela d'Oeste/SP; que os vizinhos mencionaram que havia movimentação de pessoas durante a noite, fora de hora, que chegava a incomodar; que na data da campanha houve movimentação de pessoas, mas não sabe dizer se procuravam os acusados; que não abordaram nenhuma pessoa na data; que logo que se aproximaram o acusado Higor soltou a sacola e saiu correndo, sendo que Eduarda ficou parada; que não chegou a questionar Eduarda sobre os fatos; que adentraram na residência, mas não encontraram nenhum petrecho para fracionamento da droga; que Eduarda não carregava drogas, pois Higor estava segurando a sacola; que Eduarda não resistiu à prisão.

O policial civil AUGUSTO KANAMARU, em juízo, disse que é investigador-chefe da DISE de Fernandópolis/SP; que algumas semanas antes do fato participou de uma operação oriunda da Delegacia de Estrela d'Oeste/SP, realizada na residência da mãe do acusado Higor; que na ocasião não encontraram muita droga; que o policial Gilson estava na equipe, sendo que ele é morador e já trabalhou na cidade de Estrela d'Oeste/SP; que então Gilson começou a receber informações da população, dos moradores ao redor da residência da mãe de Higor; que então começaram a apurar a prática do tráfico por parte do Higor; que fizeram um levantamento do local e viram uma movimentação típica de tráfico de drogas; que posteriormente receberam informação de que o fluxo de pessoas havia caído, indicando que poderia chegar

drogas; que então foram com duas equipes, sendo que uma delas ficou na rua que faz fundo com a residência; que fizeram campana por horas, até que um veículo encostou; que Higor e Eduarda desceram do carro, sendo que tinha um "pacote"; que tentaram abordar o carro, porém ele conseguiu sair; que quando se aproximaram, o acusado Higor já saiu correndo para os fundos do imóvel e pulou o muro, sendo abordado pela outra equipe; que quando correu, Higor abandonou o pacote, onde havia 04 (quatro) tijolos de maconha; que conduziram Higor e Eduarda para a Delegacia, pois ambos desceram do carro com o pacote; que tentou entrevistar o acusado Higor e Eduarda, porém eles não colaboraram; que não se recorda se eles indicaram de onde estariam vindo; que não se recorda a cor da sacola, porém as "barras" estavam eram de cor marrom; que não encontraram na residência petrechos para divisão de drogas; não sabe dizer quem organizava a distribuição da droga entre o casal; que Eduarda não resistiu à prisão; que nenhum dos acusados quiseram conversar no momento; que a tinha como Eduarda ter ciência do que estava dentro do saco, em razão da grande quantidade e do cheiro.

O réu HIGOR RODRIGUES VINICIUS MARIA, na fase policial (fls. 12), permaneceu silente. Em juízo, disse que não estava com Eduarda dentro do veículo; que estavam na frente da casa, quando o carro se aproximou e deixou a droga; que estava desempregado e desesperado, quando foi abordado por um rapaz num bar, propondo-lhe que guardasse esses 4kg de "maconha"; que sua mulher não tem nada a ver com isso; que lhe pediram para guardar a droga; que não iria vender; que iria guardar e receber R\$600,00 (seiscentos reais); que morava junto com sua mãe e irmã; que não morava com Eduarda; que Eduarda estava no local pois haviam brigado e ela estava ali para se entenderem; que ela não tinha ciência da droga; que era namorado de Eduarda, indo para casa dela aos finais de semana; que não tinha balança de precisão em sua casa; que é usuário de drogas; que tinha relacionamento com Eduarda há 01 (um) ano e 02 (dois) meses; que Eduarda não sabia que iria receber a droga.

A ré EDUARDA PEDROSO RODRIGUES, na fase policial (fls. 08), também permaneceu silente. Em juízo, disse que estava na calçada, ao lado de sua sogra, quando viu os policiais já entrando dentro de casa; que Higor estava dentro de casa; que um carro parou, entregou algo para Higor, sendo que em seguida ele entrou para dentro da casa; que Higor estava dentro da casa e saiu correndo; que escutou os policiais dizendo que Higor correu e pulou o muro; que não viu drogas no local; que estava namorando com Higor há 03 (três) meses; que não tinha conhecimento que Higor iria receber drogas e não residia naquele local; que ambos são usuários de drogas; que os policiais apenas disseram que estava presa em flagrante; que nunca dependeu do dinheiro de Higor.

Pois bem. Da conjugação de todas estas assertivas, entendemos como comprovado o envolvimento de ambos os acusados no encetamento do tráfico de entorpecentes - art. 33, "caput", da lei n. 11.343/06. Como é de conhecimento geral, nem sempre a polícia se vale de informações oficiais para flagrante de delitos, utilizando-se também de notitia criminis inqualificada (anônima) ou mesmo espontânea e informal abordagem de munícipes. Nesse sentido, o delito de tráfico de drogas via de regra é cometido de forma velada, às escuras, de modo que a denúncia anônima, as diligências em determinados pontos da cidade (popularmente conhecidos como "boca" de tráfico), ou mesmo a abordagem de indivíduos que, por seu histórico e informação de populares dando conta de ocorrência de delito, tem ligação ao mundo das drogas ilícitas, são formas de se apreender entorpecentes, efetuar flagrante, e dar cabo de investigações e inquéritos policiais, nos termos do art. 5º, §3º do CPP.

Na hipótese versada nos autos, os policiais já tinham recebido denúncias de populares indicando o envolvimento de ambos os acusados com o tráfico de drogas, sendo que o local dos fatos era conhecido como um "ponto" de comércio de entorpecentes. Aliás, o local dos fatos já foi alvo de busca e apreensão em investigação anterior, justamente diante das informações pretéritas do comércio ilícito de drogas no local. Da mesma forma, os populares que encetaram as denúncias

indicavam a existência de intensa movimentação de pessoas no local (notadamente "usuários"), sendo que diligências prévias realizadas pela polícia civil confirmaram tal circunstância. Ato contínuo, na data dos fatos os policiais receberam nova informação, que indicava a possibilidade de recebimento de drogas naquela data, razão pela qual os policiais realizaram "campana" no local. Assim, durante o monitoramento, os policiais visualizaram o casal de acusados saindo de um veículo com um "pacote" nas mãos, sendo que, aos realizarem a abordagem, os policiais lograram êxito em apreender grande quantidade de entorpecentes - 3,875kg de "maconha". Assim, os informes produzidos não admitem outra conclusão, senão pela configuração do delito de tráfico de drogas. Afinal, fossem "falsas" ou insubsistentes as comunicações de populares aos policiais, eles não lograriam o oportuno flagrante de chegada de drogas durante a campana, não havendo de se falar em "coincidência". Adiante, a extremada quantidade de entorpecentes encontradas em poder dos acusados (3,875kg), além das circunstâncias da apreensão, revelam indubitavelmente a destinação ao comércio e a consequente configuração do delito previsto no art. 33, "caput" de lei n. 11.343/06, o que é de certa forma admitido por Higor, embora intente afastar a responsabilidade de seus atos dizendo que agia por terceiros. Por oportuno, dificultoso (e completamente inverossímil) seria o raciocínio de não ser intuitivo que quase quatro quilos de "maconha", embaladas em "tijolos", não sejam destinadas ao comércio ilegal.

Aliás, em atenção às teses defensivas, observa-se que não há impugnação quanto à destinação comercial da droga, tendo os acusados rechaçado tão somente as circunstâncias do fato (alegam que não estavam ou saíram do interior do veículo; ou seja, estavam em casa quando o veículo "passou" e deixou os materiais), de modo a afastar a "participação" da acusada Eduarda (que alega desconhecer o entorpecente; aduz drogas foram deixadas com Higor). Entretanto, entendemos que a versão dos acusados é desarrazoada e não merece acolhida, tratando-se de subterfúgio para fugir dos rigores da lei penal. Nesse sentido, os policiais foram categóricos ao afirmar que ambos os acusados desceram de um veículo, sendo que Higor estava segurando o "pacote" onde foram encontrados os entorpecentes, sendo essa a razão da abordagem. Consequentemente, estando ambos no interior do automóvel, pouco crível que Eduarda não soubesse o conteúdo transportado, notadamente porque se trata de grande quantidade de entorpecentes, que torna difícil a ocultação (não dá pra "esconder" no bolso ou carteira, por exemplo), sendo que os policiais afirmaram que não haveria como confundir o odor que os materiais exalavam (cheiro forte). Além disso, não há sentido em Eduarda ali estar apenas para se reconciliar com Higor, mormente se os dois ali se encontravam "coincidentemente" no exato instante da chegada de drogas, e não em ambiente ou contexto íntimo.

Aliás, embora Higor argumente que "apenas" guardou os materiais para outrem, tal fato também configura a prática de um ato típico de traficância, pois, independentemente da efetiva propriedade dos entorpecentes, a guarda dos materiais para terceiros também atrai a incidência da figura prevista no art. 33, "caput", da lei n. 11.343/06. Não se ignore, entretanto, que se trata de versão que visa nitidamente afastar a responsabilidade criminal de Eduarda (argumentando que ela "não sabia"), haja vista que não apresentou mínimos detalhes que levassem a identificação da pessoa para quem, em tese, teria guardado os materiais, não indicando nome, apelido, características físicas. Repita-se, entretanto, que os policiais viram ambos os acusados saindo do interior do veículo, donde transportavam a droga, a indicar que ambos agiram em concurso para consecução do tráfico de drogas - art. 29, do CP. Vale dizer, independentemente de quem efetivamente carregava as drogas no momento da abordagem, ambos os acusados aderiram dolosamente ao comportamento criminoso, de modo que, nos termos do art. 29, do Código Penal, quem de qualquer modo concorre para a prática do crime, responde às penas que a ele são cominadas. Assim, na prática de delitos em concurso de agentes, previamente conluiados, os comparsas aderem às condutas entre si, sendo irrelevantes os detalhes de qual tarefa coube a cada um deles, respondendo cada um pelo todo. Portanto, de rigor a condenação de ambos os acusados pelo delito de

tráfico de drogas – art. 33, "caput", da lei n. 11.343/06.

Por outro lado e em sentido distinto, entendemos que a mesma solução não pode ser dada quanto ao delito previsto no art. 35, "caput", da lei n. 11.343/06 – "associação para o tráfico". Com efeito, o delito em questão exige para sua configuração demonstração inequívoca de que os envolvidos estavam associados com ânimo definitivo e de maneira estável para a consecução da traficância. E, na presente hipótese, entendemos que poucos elementos de convicção se direcionam no sentido de que os réus agiam de maneira estável e com vínculo permanente. Vale dizer, o simples fato de manterem união estável (ou simples namoro, como alegaram), por si só, não conduz automaticamente a tal conclusão. Da mesma forma, pese estarem juntos no momento da abordagem, não houve demonstrativo suficiente da prática reiterada de atos anteriores, de modo estável e permanente, não sendo suficiente, para tanto, as meras denúncias informais (que não indicavam nenhum fato concreto). Assim, na verdade, entendemos que os réus agiram em concurso de agentes (art. 29, do Código Penal) para a prática do tráfico de drogas (como já fundamentado anteriormente), sendo robustas as provas nesse sentido, de modo que as afirmações dos policiais (relatando atos anteriores e informes de populares) são mesmo aptas a, em conjunto com a diligência do dia 22/09/2021, configurarem prova suficiente da traficância (tanto que os policiais lograram apreensão quando da campana). No entanto, para o delito de associação, seria necessária maior concretude dos elementos "estabilidade" e "permanência", de forma análoga à existente quando da apreensão específica do dia 22 (outras apreensões, comunicações colhidas, testemunhas, entre outros). Nesse sentido:

"(...) Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes. 3. O Tribunal a quo, tendo reconhecido que a reunião do paciente e os demais corréus teria sido eventual, a admitiu como apta a configurar o delito de associação para o tráfico, o que contraria a interpretação majoritária que tem sido conferida ao tipo do artigo 35 da Lei de Drogas. 4. Não havendo qualquer registro, quer na denúncia, na sentença condenatória, ou no aresto objurgado, de que a associação do paciente com os demais sete corréus teria alguma estabilidade ou caráter permanente, não há que se falar no delito de associação para o tráfico, estando-se diante de mero concurso de pessoas..." (HC 208.886/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 08/11/2011, DJe 01/12/2011).

Assim, não tendo sido demonstrada a existência de ânimo associativo estável e organizado, ainda que o concurso de agentes esteja indicado, a absolvição é medida mais adequada.

Verificamos, portanto, que a versão dos acusados, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidência, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Passo à fixação da pena.

I – HIGOR VINICIUS RODRIGUES MARIA

Em primeira fase, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e ainda ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, temos, a merecer valoração negativa a culpabilidade do acusado. Com efeito a quantidade elevada de entorpecentes apreendidas em seu poder (3,875kg de "maconha") confere contorno de gravidade diferenciada ao caso e culpabilidade anormal ao tipo penal. A quantidade de entorpecentes apreendida com os acusados evidencia maior afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal, qual seja, a "saúde pública", que é violada com

qualquer ação típica que envolve pequenas quantidades. Ou seja, ao revés das pequenas porções, a quantidade de entorpecentes, se colocada em circulação, atingiria elevado número de pessoas, havendo de ser valorada. O próprio art. 42 da Lei n. 11.343/06 impõe a ponderação, no momento da fixação das penas, da "natureza e a quantidade da substância ou do produto". Por tais razões fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes que possam alterar a dosagem da pena. Frise-se que, por analogia ao disposto na súmula n. 630 do STJ, a incidência da confissão espontânea exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, o que não ocorreu na hipótese dos autos, eis que se limitou a dizer que guardava o entorpecente para terceiros, sem oferecer maiores detalhes quanto à destinação. Vale dizer, o acusado não admitiu a prática dos verbos descritos na inicial acusatória (adquirir; e transportar), e em nada colaborou, de modo que não faz jus à atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.

Em sequência, considerando agora as causas de aumento e diminuição da pena (terceira fase de dosimetria), não há igualmente causa para alteração do quantum. Anote-se, nessa fase, que é inaplicável ao autor Higor a redutora do art. 33, §4º, da lei n. 11.343/06, afinal o referido dispositivo legal autoriza a redução da pena "desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". Frise-se que são requisitos cumulativos, sendo que a comprovação da satisfação do requisito legal de certo modo que praticamente se inverte o ônus da prova, incumbindo ao próprio interessado demonstrar que a atividade criminosa em que foi pego constituiu episódio esporádico, preferencialmente o único em sua existência, vale dizer, o propalado e informal "traficante de primeira viagem". E essa prova não foi produzida. Ao revés, das circunstâncias evidenciadas nos autos (notadamente a extremada quantidade de entorpecentes) é possível extrair que o acusado se dedicava efetivamente ao tráfico. Nesse sentido, os policiais informaram que já tinham recebido denúncias indicando que o acusado se dedicava à prática do tráfico, isto há mais de 06 (seis) meses, sendo que ele foi alvo de busca e apreensão cerca de 15 (quinze) dias antes dos fatos e mesmo assim voltou a se envolver com drogas ilícitas. Vale dizer, mesmo ciente de que suas atividades já eram investigadas pela polícia (já que foi alvo de busca), mesmo assim não alterou seu comportamento, adquirindo e transportando grande quantidade de drogas. Vale mencionar, ainda, que o próprio acusado se declarou desempregado, ou seja, não tinha vínculo empregatício lícito, sendo que, conjugados tais fatores à grande quantidade de entorpecentes apreendidas, depreendem-se elementos concretos que denotam dedicação efetiva às atividades criminosas. Da mesma forma, forçoso considerar que o acusado não possui "bons antecedentes" (como exige o dispositivo legal), pois a "primariedade" não se confunde com "bons antecedentes".

Nesse ponto, um réu é primário se não teve condenação criminal anterior. Tem bons antecedentes se ostenta vida pregressa limpa, bom conceito social, reputação ilibada, nenhum envolvimento com o crime." (STJ - RHC 4965 SP 1995/0052715-4). E, na presente hipótese, o acusado Higor é conhecido na comarca em razão de práticas anteriores de atos infracionais, e inclusive já foi condenado pela prática de ato infracional de homicídio - art. 121, do CP (no proc. 1500021-38.2018.8.26.0561, com decisão confirmada pelo E. TJSP). Por oportuno, juntamos aqui trecho de sentença e acórdão lá prolatados (com trânsito em 22/04/2019; fl. 308 daqueles autos), restando fixada a sua internação à época:

"Passo à fixação da medida. No contexto de proteção integral proposto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas socioeducativas possuem caráter protetivo e não punitivo, e tendem a interferir no processo de desenvolvimento do adolescente, objetivando propiciar uma melhor compreensão da realidade e efetiva integração

social. No caso concreto, o adolescente ostenta outras passagens por atos infracionais (duas anotações de tráfico de drogas e outra por ameaça fls. 222ss e 234ss). Da análise das infrações anteriormente praticadas mostra-se nítida a escalada na prática de atos infracionais por parte do adolescente, pois seu primeiro envolvimento em ato infracional foi, em tese, por delito 'leve' (ameaça fls. 234), havendo, nos últimos tempos, ascensão para delitos de gravidade extremada, como o tráfico de drogas e, agora, em homicídio doloso. Pontue-se que este juízo, por diversas ocasiões, advertiu e aconselhou o adolescente sobre o envolvimento com más companhias, na tentativa de inibir seu ímpeto em se envolver na prática de atos infracionais, o que não restou suficiente, pois nenhum efeito positivo restou demonstrada na conduta do adolescente. A terapêutica até aqui aplicada pelo Estado, de forma clara, foi inócua para o adolescente. Em repetição ao já adiantado, o adolescente ostenta duas anotações anteriores por tráfico de drogas, havendo relatos nos autos de que sua própria genitora auxilia na compra de entorpecentes (fls. 134), mencionando, ainda, fazer uso de crack e cocaína (fls. 154). No processo de maior extensão e complexidade em andamento nesta Comarca (proc. 1068-22.2017), versando sobre associação para o tráfico (no qual existem 23 réus e 20 deles presos), o nome do adolescente é citado por envolvimento em um tráfico específico e associação. E agrava ainda mais o quadro do menor a evidente ausência de respaldo familiar. A genitora não possui qualquer ascendência sobre o menor, que permanece maior parte do tempo na rua. Segundo o estudo social: 'o mesmo não tem a mãe como figura de autoridade, se apresentando sem limites, sem parâmetros, estabelecendo amizades nefastas no local onde mora, se afastando da escola' (fls. 171). Em tempo, o próprio adolescente mencionou que não estava frequentando as atividades escolares antes do ato ora julgado. No relatório de fls. 138, relativo ao período em que o adolescente frequentava a escola, há menção de condutas reprováveis e comportamento extremamente inadequado no ambiente escolar, tais como agressão a colegas, enfrentamento de professores, vocabulário chulo e até mesmo 'agarrando as meninas pelas costas para beijá-las à força' (fls. 138), ou seja, todos elementos indicativos da necessidade de medida mais drástica para orientação ao adolescente" (destaques meus; trecho de sentença, fls. 243/244 dos autos 1500021-38.2018.8.26.0561).

"Usuário de maconha e faltoso na escola, o apelante, segundo apurado no relatório da assistente social judiciária (pp.167/171), mantinha amizades suspeitas e tinha o hábito de chegar a casa altas horas da noite e dormir até a tarde do outro dia. E, quanto aos fatos, Higor contou para a genitora (p.170) que jamais pensara que o rapaz tinha vindo a óbito, pois se soubesse, tanto ele como o outro amigo que estava junto teriam fugido. As condições pessoais e o forte influxo delinquencial que permeia o curso de formação da personalidade do educando desautorizam a troca do regime estabelecido, pela simples razão de sua inaptidão pedagógica, para atender a demanda de que se ressesse o apelante" (destaques meus; trecho de acórdão do E. TJSP, fls. 303 dos autos 1500021-38.2018.8.26.0561).

Aliás, em consulta ao "Portal da Fundação Casa", observa-se que o acusado terminou o cumprimento da medida socioeducativa que lhe fora imposta no final de 2020, a denotar que em pouco tempo já voltou a se envolver em fatos graves. Registre-se que o C. STJ admite a utilização de atos infracionais para afastamento da forma privilegiada, considerando a gravidade dos atos pretéritos e a proximidade com a nova infração, exatamente como ocorre nos autos. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA. USO DE ATOS INFRACIONAIS COMO INDICATIVO DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PELA DELAÇÃO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA. 1. Embora o ato infracional possa, na plano fático, ser tão daninho como o crime (os fatos sociais, portanto, não mudam de natureza), seria lícito concluir que, por opção do legislador, os mundos da inimputabilidade e da imputabilidade em princípio não se intercambiam em termos penais punitivos, embora a compreensão majoritária da 3ª Seção seja pela possibilidade de negativa do redutor. 2. No julgamento dos Embargos

de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, em 08/09/2021, a Terceira Seção, consolidando a sua jurisprudência, firmou compreensão de que o histórico infracional do acusado pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, "por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração." (EResp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021). (...) 8. Habeas corpus denegado. (HC 660.874/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Assim, considerando seu histórico, bem como que o acusado tinha em depósito relevante quantidade de entorpecentes, bem como que em seu desfavor foram produzidos elementos que não indicam singularidade e unicidade no seu comportamento ilícito, não se pode conferir a ele, diante destas peculiaridades, o mesmo tratamento que de dispensaria àquele que comercializa pequena quantidade de entorpecente, não demonstrando se tratar de um mero iniciante na seara criminal.

Enfim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) ANOS e 10 (dez) MESES de RECLUSÃO e 583 (quinhentos e oitenta e três) DIAS-MULTA, no seu valor mínimo legal.

Para início de desconto da pena, estabeleço o regime FECHADO. Reporto-me, para tanto, às circunstâncias judiciais negativas consideradas, à imposição do art. 2º, §1º da Lei 8.072/1990 (crime equiparado a hediondo) e à insuficiência de eventual regime diverso. Com efeito, a despeito de a condenação ser inferior a 8 (oito) anos, a opção do legislador pelo verbo "poder" (art. 33, § 2º, "b" e "c") conferiu ao magistrado espaço para individualizar o regime inicial de acordo com o caso concreto. Na hipótese, a mercancia ilícita de entorpecentes possui efeitos ainda mais nocivos quando praticados em cidades de diminuta extensão e população, eis que tornam acessíveis drogas de efeitos extremamente deletérios a pessoas que não teriam alcance ao entorpecente se encontrassem maior dificuldade em sua aquisição, o que demonstra a intensidade da violação do bem jurídico protegido pela norma penal, evidenciando a necessidade da adequada resposta estatal. Assim, a aplicação de regime mais brando não parece adequada no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal e atender os princípios da reprovação e prevenção.

Por fim, incabível a concessão do sursis penal (CP, art. 77) ou da substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44), em razão do quantum de pena estabelecido (quantidade de pena ora aplicada supera os parâmetros máximos autorizadores), além do que as circunstâncias do caso concreto não demonstram que a aplicação de tais benesses sejam suficientes para reprovabilidade da conduta.

II – EDUARDA PEDROSO RODRIGUES

Em primeira fase, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e ainda ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, temos, a merecer valoração negativa, a culpabilidade da acusada. Com efeito a quantidade elevada de entorpecentes apreendidas em seu poder (3,875kg de "maconha") confere contorno de gravidade diferenciada ao caso e culpabilidade anormal ao tipo penal. A quantidade de entorpecentes apreendida com os corréus evidencia maior afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal, qual seja, a "saúde pública", que é violada com qualquer ação típica que envolve pequenas quantidades. Ou seja, ao revés das pequenas porções, a quantidade de entorpecentes, se colocada em circulação, atingiria elevado número de pessoas. O próprio art. 42 da Lei n. 11.343/06 impõe a ponderação, no momento da fixação das penas, da "natureza e a quantidade da substância ou do produto". Por tais razões fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes que possam alterar a dosagem da pena. Em sequência, considerando agora as causas de aumento e diminuição da pena (terceira fase de dosimetria), entendemos excepcionalmente aplicável a ela a redutora do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que, embora tenha aderido à conduta de Higor, não há maiores elementos negativos em seu desfavor e em seu histórico. Vale dizer, a acusada não possui antecedentes criminais, informou que possui emprego lícito e nada indica que se dedique exclusivamente as atividades criminosas, sendo, possivelmente, no caso dos autos, mais influenciada por Higor do que habitual pessoa vinculada a ilícito. Assim, entendemos que a acusada faz jus à redução em seu grau máximo, no patamar de 2/3 (dois terços).

Enfim, fixo a pena definitiva em 01 (um) ANO, 11 (onze) MESES e 10 (dez) DIAS de RECLUSÃO e 194 (cento e noventa e quatro) DIAS-MULTA, no seu valor mínimo legal.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à condenação inferior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 33, § 2º, "c"), bem como à não reincidência e o afastamento do caráter hediondo pelo STF (HC 118.533/MS; Rel. Min. Carmem Lúcia), deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime ABERTO.

A acusada é primária e as circunstâncias do crime indicam que a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos é suficiente. Desse modo, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade ora aplicada, por duas restritivas de direitos, sendo a primeira dela de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, que se dará pelo prazo total de pena restritiva de liberdade, em entidade a ser designada pelo Juízo das Execuções Criminais; e a segunda de PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor de 02 (dois) salários mínimos, a ser revertido em favor de entidade assistencial da comarca.

Do dispositivo.

Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e assim faço para o fim de:

CONDENAR o réu HIGOR RODRIGUES VINICIUS MARIA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) ANOS e 10 (dez) MESES de RECLUSÃO e 583 (quinhentos e oitenta e três) DIAS-MULTA, no seu valor mínimo legal, a ser cumprida em regime inicial FECHADO.

CONDENAR a ré EDUARDA PEDROSO RODRIGUES, já qualificada nos autos, como incurso no art. 33, §4º, da lei n. 11.343/06, à pena de 01 (um) ANO, 11 (onze) MESES e 10 (dez) DIAS de RECLUSÃO e 194 (cento e noventa e quatro) DIAS-MULTA, no seu valor mínimo legal, a ser cumprida em regime inicial ABERTO. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade ora aplicada, por duas restritivas de direitos, sendo a primeira dela de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, que se dará pelo prazo total de pena restritiva de liberdade, em entidade a ser designada pelo Juízo das Execuções Criminais; e a segunda de PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor de 02 (dois) salários mínimos, a ser revertido em favor de entidade assistencial da comarca

ABSOLVER os acusados HIGOR VINICIUS RODRIGUES MARIA e EDUARDA PEDROSO RODRIGUES, já qualificados, quanto à imputação do delito inscrito no art. 35, "caput" da lei n. 11.343/06, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não reconheço ao réu HIGOR o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme

discriminado na fundamentação, havendo risco de que venha novamente a delinquir enquanto não cumpra a pena. Há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar a tutela jurisdicional definitiva, atentando-se contra a ordem pública, mesmo considerando o término da instrução. Dos elementos produzidos, conclui-se que o acusado ostenta risco à ordem e saúde públicas, devendo permanecer encarcerado para a proteção da sociedade. Dos dizeres dos policiais e do próprio histórico de Higor se denota que ele, solto, nessas condições (habitualmente vinculado ao mundo do crime), certamente voltará a delinquir e expor a população local às suas práticas. Ante o exposto e com fulcro nos artigos 311, 312, 313 e 387, parágrafo único, todos do CPP, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se recomendação, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação, ao estabelecimento em que se encontra recolhido, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão (item 59.1, Cap. V, das NCGJ).

Já em relação à acusada EDUARDA, por estar em liberdade e não haver causa superveniente para decretação de prisão (art. 312, CPP), DEFIRO à ré o direito recorrer e aguardar julgamento em liberdade.

Por fim, não comprovado o uso do aparelho celular apreendido para o encetamento do delito, autorizo sua devolução à acusada Eduarda. Nos termos do art. 123 do Código de Processo Penal, aguarde-se o prazo de 90 (noventa) dias, a contar do trânsito em julgado, para que as partes e/ou interessados reclamem a propriedade/restituição dos materiais apreendidos, sendo que, caso permaneçam silentes, os objetos serão encaminhados à destruição, pois não mais interessam à instrução. Oportunamente, comunique-se o Setor de Guarda de Armas e Objetos para providências cabíveis.

No mais, condeno os réus, ainda, a pagarem as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), observada eventual gratuidade processual. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Oportunamente, expeça-se guia de execução definitiva. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Estrela D'Oeste, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA